



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/576/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת הבכירה יעל ענתבי-שרון

התובעת	1	קליר בתיה באמצעות ב"כ עו"ד גלית אילן
נתבעים	1	יחזקי יוסף
	2	יחזקי עשירה באמצעות ב"כ עו"ד יצחק מ. ליפשיץ
		נגד

פ ס ק - ד י נ

עניינו של פסק דין זה בקביעת העלות בה על התובעת לשאת לשם עשיית שימוש במעלית המותקנת בבית המשותף ולעת עתה משמשת את הנתבעים בלבד.

א. עיקרי העובדות

- הליך זה עוסק בבית משותף הידוע כגוש 6160 חלקה 497 הממוקם ברחוב ז'בוטינסקי 43 בגבעתיים (להלן: "הבית המשותף"). הבית המשותף הוא בן 3 קומות ובו 12 תתי חלקות. התובעת היא בעלת הדירה הידועה כתת חלקה 4 ששטחה 60.6 מ"ר והיא ממוקמת בקומה הראשונה בבית המשותף (להלן: "דירת התובעת"). הנתבעים הם בני זוג, בעלי שתי דירות הידועות כתתי חלקות 11 ו-12 אשר שטחן 60.52 מ"ר ו- 59.83 מ"ר בהתאמה. דירות אלו שוכנות בקומה השלישית של הבית המשותף (להלן: "דירות הנתבעים"). לבית המשותף תקנון מוסכם.
- הבית המשותף נרשם בשנת 1971, ונבנה ללא מעלית. במהלך שנת 2004 הותקנה בבית המשותף מעלית בהתאם להיתר בנייה, כאשר אין חולק כי שימשה מאז הקמתה ועד שנת 2018 את דירות הנתבעים בלבד והם גם אלו שנשאו לבדם בכל העלויות הכרוכות בהתקנה ותחזוקת המעלית. בהתאם להסדר שהושג בין הצדדים בהליך (עליו יורחב בהמשך), החלה הנתבעת לעשות שימוש במעלית במהלך אוגוסט 2018.
- הנתבעת, בשנות התשעים לחייה, פנתה לנתבעים בשלהי שנת 2018 בבקשה לעשות שימוש במעלית תמורת תשלום חלקה היחסי בהוצאות התקנתה. משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות באשר לגובה התשלום בו על הנתבעת לשאת כתנאי לשימושה במעלית, הגישה התובעת תביעה זו בה עתרה לחייב את הנתבעים לאפשר לה שימוש במעלית, וזאת בכפוף לתשלום חלקה בהוצאות התקנתה העומד, לשיטתה, על 16.66% (שטח דירתה ביחס ליתר שטחי הדירות בבית המשותף), וכן לחייב את הנתבעים בהצגת מסמכים הנוגעים לעלויות התקנת המעלית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/576/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. ביום 29.7.18 הוגשה "בקשה דחופה למתן סעד זמני" במסגרתה התבקש להורות למשיבים כדלהלן: **"למסור מפתח המעלית למבקשת וכן לעשות כל פעולה החלה עליהם על פי הדין להפעיל המעלית בקומת המבקשת ולשימושה"**. במהלך הדיון בבקשה זו, אשר התקיים ביום 12.8.18, בנוכחות ילדי התובעת, הנתבעים ובאי כוחם, הגיעו הצדדים להסכמה הבאה:

"הגענו להסכמה לפיה המשיבים יאפשרו למבקשת שימוש מיידי במעלית בכפוף לתשלום בסך ₪ 75,000. מובהר כי אין מדובר בסכום הסופי, אשר יקבע בסיומו של ההליך, אלא בסכום ביניים לשם קבלת אפשרות לשימוש במעלית. המבקשת תישא בעצמה בכל עלויות התאמת המעלית לעצירה בקומה הראשונה בה ממוקמת דירתה כל עוד הסכום לא יעלה על 3,000 ₪. ככל שהעלות תהיה מעבר ל-3,000 ₪ יקבע בסיום ההליך מי צריך לשאת בעלות שמעבר לסכום זה. כמו כן תישא המבקשת בשליש מכל הוצאות האחזקה השוטפות של המשיבים מיום התחלת השימוש בה. המשיבים ישתפו פעולה בכל הנדרש, בין היתר מול חברת המעליות אלקטרה, לצורך ביצוע התאמה לצרכי המבקשת. המשיבים יעבירו לבאת כוח המבקשת את שם איש הקשר בחברת המעליות מיד לאחר ועוד באותו יום של ביצוע התשלום כאמור לעיל. למען הסר ספק המבקשת לא תאפשר לבעל דירה אחר לעשות שימוש במעלית מבלי שיגיע להסדר תשלום עם המשיבים. ילדיה של המבקשת, אורית קליר יניצקי 57279218 ודוב קליר 51661296 יהיו ערבים אישית, ביחד ולחוד, לתשלום שיחול על המבקשת בסיום ההליכים ככל שיהיו גבוהים מהסכום האמור לעיל (75,000).

... לצורך הכרעה בהליך העיקרי מוסכם כי כל צד יגיש אסמכתאותיו וטיעוניהם המשפטיים ללא צורך בחקירות או בדיון נוסף ועל בסיס חומר זה והטיעונים יינתן פסק הדין... מובהר כי הפיכת סדר הבאת הראיות היא רק לצורכי נוחות ואין בכך כדי להפוך את נטל ההוכחה והראייה".

5. בהתאם להסכמת הצדדים, החלה התובעת לעשות שימוש במעלית לאחר ששילמה לנתבעים סך של 75,000 ₪ וכן נשאה בסך של 1,000 ₪ נוספים לשם התאמת המעלית לצרכיה. סיכומי הנתבעים הוגשו ביום 29.8.18, סיכומי התובעת ביום 14.10.18 וסיכומי התשובה ביום 31.10.18.

ב. עיקרי טענות הנתבעים

6. הנתבעים טוענים כי בעת הקמת המעלית בחרה התובעת יחד עם יתר בעלי הדירות שלא להשתמש בה, כאשר התובעת אף הייתה אחת המתנגדות הבולטות להקמתה. נטען כי התובעת, כמו גם יתר בעלי הדירות בבית המשותף, הסכימו לכך שהנתבעים יישאו בהוצאות ההתקנה והתחזוקה של המעלית לבדם והיא תשמש אותם באופן בלעדי. בהתאם לכך הנתבעים לקחו על עצמם לשאת בכל העלויות הכרוכות בהקמת המעלית מיום הקמתה.

7. הנתבעים טוענים כי התובעת ויתר בעלי הדירות סירבו להכיר במעלית כחלק מן הרכוש המשותף וכראיה לכך סירבו לשאת בכל הוצאה הנדרשת להתקנה או לתחזוקה של המעלית. לטענת הנתבעים כל בעלי הדירות בחרו לנהל את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/576/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

היחסים ביניהם בהתאם להסכמה שנהגה בין הצדדים, לפיה רק הנתבעים נושאים במלוא הוצאות התקנת ותחזוקת המעלית. לטענתם, הסכמה זו נהגה מכוח סעיף 159(ג)(1) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") ולא לפי סעיפים 159(ב)(1) ו-159(ב)(3) לחוק, הקובעים באופן מפורש על מי תחול חובת התשלומים. לטענת הנתבעים, הסכמה זו מלמדת על כך שמדובר במעלית פרטית.

8. לפיכך, לטענת הנתבעים, על התובעת לשאת **במחצית** ממלוא הוצאות ההתקנה התחזוקה השוטפת, שכן, לטענתם, כך יאה לחייב את מי שמבקש להיכנס כשותף לנכס שקודם לכן התעקש לנתק איתו כל זיקה או אחריות. הנתבעים טוענים כי יש לחייב את התובעת גם בנזקים שנגרמו להם בשל העיכוב בהקמת המעלית אשר נבע מהתנגדותה להקמתה, עיכוב אשר לטענתם הוביל אותם להוציא כספים בגין דמי שכירות ודמי הובלה לדירה השכורה.

9. הנתבעים טוענים כי מעבר להוצאות התקנת המעלית, יש לחייב את התובעת גם בהוצאות התחזוקה וההפעלה החל ממועד התקנת המעלית. לטענתם, על מנת להותירה במצב תקין היה על התובעים לשאת בהוצאות ועל כן על התובעת לשלם את חלקה. עוד נטען כי ממילא לפי ברירת המחדל הקבועה בסעיף 159 לחוק, מחויבים כלל הבעלים לשאת בהוצאות הפעלת ותחזוקת המעלית מיום הקמתה.

10. לחלופין טוענים הנתבעים כי גם אם יימצא שחלות במקרה הנדון הוראות סעיפים 159(ב)(1) ו-159(ב)(3) לחוק, יש לקבוע כי יחס החלוקה איננו לפי יחס רצפות כלל דיירי הבית המשותף אלא רק לפי יחס הרצפות של הדירות "שבעליהן נושאים באותם התשלומים", ובמקרה דנן- שיעור חלקה היחסי של הנתבעת אינו פחות מ-33.5%.

11. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי במקרה דנן יש להשית על התובעת גם הפרשי הצמדה וריבית. לטענתם, עם הגשת התביעה הפרה התובעת את הסכמת הצדדים ובחרה להתייחס למעלית כרכוש שלה חרף העובדה שמלכתחילה בחרה לנתק כל זיקה למעלית. נטען, כי אף אם היו הנתבעים מקבלים את עמדת התובעת לפיה חלות על המקרה הנדון הוראות סעיף 159 לחוק, אלו הטילו מלכתחילה על התובעת את החובה לשאת בהוצאות ההפעלה והתחזוקה וממילא היה עליה לשאת בחיוב זה לפני שנים והיא לא עשתה כן. נטען, כי יש לחייב את התובעת גם בתוספת ריבית על ההצמדה שכן אין זה משנה אם תשלום כרוך באשם או לא. לטענתם, מגמת החיוב בריבית אינה להעניש אלא לוודא שההשבה של כספים שהוצאו תגיע לכדי הסכום הריאלי ששולם.

12. הנתבעים טוענים כי על התובעת לשלם להם בסך הכל סכום של 330,450 ₪.

ג. עיקרי טענות התובעת

13. התובעת טוענת כי יש לדחות מכל וכל את טענת הנתבעים כי מדובר במעלית פרטית, או כי הייתה הסכמה בין בעלי הדירות שמדובר במעלית פרטית. התובעת טוענת כי המעלית נבנתה ברכוש המשותף ועל כן היא גם מהווה חלק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/576/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מהרכוש המשותף. לטענתה, מעולם לא הוסכם בין בעלי הדירות על התקנת מעלית פרטית ברכוש משותף ואין כל ראייה המוכיחה זאת. נטען, כי גם אין כל הוראה בתקנון מוסכם או באסיפה כללית הקובעת כך. לטענתה, כלל לא ניתן להצמיד מעלית לדירה בבית משותף, וזאת נוכח האמור בסעיף 55 לחוק. התובעת מוסיפה וטוענת כי הטענה לפיה מדובר במעלית פרטית הועלתה לראשונה רק בסיכומים ועל כן המדובר בהרחבת חזית פסולה.

14. לטענת התובעת, התנגדותה בעבר להקמת המעלית הייתה נעוצה בסיבות מוצדקות – הצרת המדרגות, החשכתו וכיוצא, אולם משעה שהתנגדה והתנגדותה נדחתה לא ערערה על ההחלטה ולא פעלה בשום דרך אחרת לעכב את בניית המעלית.

15. התובעת טוענת כי הנתבעים היו היחידים לממן את עבודות התקנת המעלית שכן באותה עת אף אחד מבעלי הדירות לא הביע רצון להשתתף בפרויקט בניית המעלית. נטען, כי המעלית נבנתה ברכוש המשותף בבניין, חדר המכוניות נבנה בקומת הקרקע, המעלית נבנתה עם תחנות יציאה לכל קומה. בשים לב לכך נטען כי המעלית מהווה חלק מהרכוש המשותף וחלות עליה הוראות סעיף 59' לחוק. על כן, טוענת התובעת, עומדת לה הזכות לעשות שימוש במעלית זו.

16. בהקשר לעלות המבוקשת כתנאי לשימוש במעלית, טוענת התובעת כי דרישת הנתבעים משוללת כל יסוד. לטענתה, על בסיס סעיף 59(ב)(1) לחוק יש לקבוע כי הבסיס לתשלום עבור שימוש במעלית הוא בהתאם לשטח הרצפה של הדירה ביחס לכלל שטח הרצפות של דירות הבית המשותף, ולפיכך חלקה היחסי בגין תשלום הקמת המעלית הוא 16.66% בלבד.

17. לטענת התובעת, לא ניתן לדעת מהי עלות בניית המעלית, שכן הסכם ההתקשרות עם חברת המעליות לא צורף לכתבי הטענות. נטען כי לא הוכח מה כולל הסכום ששולם לחב' המעליות אמיקופ, לפי איזה שער דולר חושב הסכום והאם העבודות שבוצעו היו קשורות לבניית המעלית והפעלתה. התובעת מציינת כי אי גילוי ההסכם מעלה חשש לכך שהנתבעים שילמו סכום נמוך מהסכום אותו הם דורשים עתה עבור התקנת המעלית.

18. התובעת טוענת כי בהסתמך על האסמכתאות שהציגו הנתבעים, עלות התקנת המעלית בצירוף הפרשי הצמדה בלבד היא 295,663 ₪. לטענתה, יש להפחית מסכום זה עלות משוערת שביצעו הנתבעים בגין בניה התאמת המעלית לתקן, סכום הנאמד ב- 30,000 ₪, ועל כן חלקה בתשלום (16.66%) עומד על 43,160 ₪ בלבד. התובעת טוענת כי את הפרשי ההצמדה יש לחשב עד חודש מרץ 2018 בלבד, אז ביקשה התובעת לשלם עבור המעלית- וסורבה. בפועל, נטען, שילמה התובעת תשלום זמני בסך של 75,000 ₪ ותשלום נוסף של 1,000 ₪ עבור התאמות שבוצעו במעלית ועל כן, לטענתה, היא זכאית להשבה של 32,840 ₪.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/576/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. לטענת התובעת, אין לחייבה בהוצאות אחזקת המעלית באופן רטרואקטיבי. לשיטתה, לא השתמשה במעלית במהלך השנים ואף לא הייתה לה כל גישה למעלית. התובעת טוענת כי כל עוד לא ניתן לעשות שימוש במעלית ואכן לא נעשה שימוש בפועל, אין כל בסיס המצדיק לדרוש את השתתפותה בהוצאות אחזקת המעלית. נטען כי דרישה זו היא גם חסרת תום לב, שכן היא מועלית 14 שנים לאחר התקנת המעלית. התובעת טוענת עוד כי כבר נקבע שבדרישה מסוג זה יש משום עשיית עושר ולא במשפט. בהקשר זה מפנה התובעת לפסק דינו של כב' המפקח א. סילברמן (כתוארו דאז) בתיק (מפקח) 96/11, אלי רוזין נ' נציגות הבית המשותף מרח' חרוזים 28 רמת גן [פורסם בנבו, 14.4.11].

20. התובעת טוענת כי יש לדחות את דרישת הנתבעים לחייבה בנזקיהם הנתבעים, מאחר ואלו כלל לא הוכחו. בנוסף נטען כי הפסיקה הדנה בעלות שיש להשית במקרה בו בעל דירה עושה שימוש במעלית שהותקנה זה מכבר נוגעת אך ורק להוצאות הישירות של ההתקנה ולא לשום הוצאה עקיפה אחרת.

21. התובעת מוסיפה וטוענת כי יש לדחות גם את דרישת הנתבעים לחייבה בהפרשי ריבית. נטען, כי חיוב בריבית מושת כפיצוי עונשי כאשר מדובר בחוב שלא שולם במועדו, כאשר במקרה דנן לא מדובר בחוב כלל. לטענתה, במועד התקנת המעלית לא נדרש ממנה לשלם את חלקה בעלות התקנת המעלית משלא עשתה בה שימוש כלל ולכן לא נוצר חוב באותו המועד. עוד נטען כי המקרה דנן אינו עונה להגדרה של התעשרות שאינה כדין וכי אם הנתבעים יזוכו גם בהפרשי ריבית יהיו דווקא הם אלו שיתעשרו שלא כדין.

22. סיכומו של דבר, טוענת התובעת, כי נוכח התנהלות הנתבעים אשר עמדו על השתתפותה בעלות מופרזת ואילווצה להגיש תביעה זו, יש לחייבם בהוצאות משפט, לרבות הוצאות אישיות לטובת ילדיה, ושכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין.

ד. דיון והכרעה:

23. סעיף 59 ו' לחוק אשר עניינו בהקמת מעלית ברכוש המשותף, קובע כך-

- "(א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:
- (1) ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
 - (2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.
 - (ב) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם ישאו בהוצאות כאמור;
 - (2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה;
 - (3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית;
 - (4) התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/576/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.
(ג) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם;
(2) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית.
(ד) (1) ההוראות בפרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחוייבים;
(2) המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה, על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי שימצא לנכון".

24. הוראת סעיף 59 ו' עוסקת, אפוא, כעולה מלשונה ותכליתה, בהתקנת מעלית משותפת הנותרת חלק מהרכוש המשותף. על מנת שמעלית תוכר כמעלית "פרטית" יש צורך בהסכמה של כל בעלי הדירות לכך, שכן הוצאת חלק מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה פלונית דורשת הסכמת כל בעלי הדירות (ראה סעיף 62 (א) לחוק הקובע כי "...אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"). במקרה הנדון אין כל טענה, קל וחומר ראייה, כי כל בעלי הדירות הסכימו להצמדה של המעלית לדירת הנתבעים. כך, גם אין כל הוראה בתקנון המוסכם של הבית המשותף ובמרשם המקרקעין הקובעת כך. משכך, ברי כי מדובר במעלית המהווה רכוש משותף ועל כן דין טענת הנתבעים כי מדובר במעלית "פרטית" להידחות. בהקשר זה ראו גם פסק דיני בתיק (מפקח ת"א 908/17 כהן נ' אהרון (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 20.12.18), שם נדונה הסוגיה בהרחבה - (להלן: "פרשת כהן").

25. לכל היותר, ניתן לראות את המעלית כמתקן משותף אשר ניתנה לנתבעים זכות השימוש ייחודית בה לאורך שנים. אין חולק בין הצדדים כי בפועל עשו הנתבעים שימוש ייחודי במעלית לאורך שנים. אמנם, גם לזכות שימוש ייחודי נדרשת הוכחת הסכמת כל בעלי הדירות (ראה: ת"א (מחוזי-ת"א) 2816/03, צפורה קונצ'יצקי נ' דליה שפלן, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 3.4.06, ע"א 2525/92, גבי וקרני ראובברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850, רע"א 698/85, בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', תק-על 87 (2) 732, א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק ג', 114-115). אולם, להבדיל ממתן זכות קניינית, ביחס אליה נדרשת הסכמה מפורשת בכתב שבהמשך מעוגנת בתקנון וברישום הבית המשותף, כאשר עסקינן במתן זכות שימוש ייחודית במקרקעין, אזי ניתן ללמוד על הסכמה גם על דרך של הסכמה שבשתיקה, הסכמה מכללא, על דרך בחינת התנהגות הצדדים במשך השנים וכיוצב'. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור רישיון מכללא (ראה: ע"א 32/77, טובוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא (3) 210, ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06 רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח' (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 7.8.07), פרופ' נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב' חוברת א', בעמ' 128). להבדיל מהסכמה למתן זכות קניינית, הנרשמת במרשם המקרקעין ולא ניתן לחזור ממנה, הסכמה למתן זכות שימוש במקרקעין היא זכות אישית, ממנה ניתן לחזור בכל עת (ראה: זלצמן, בעמ' 57, מ. דויטש, קניין, כרך ב' (התשנ"ט-1999), 414). רק במקרים מיוחדים, בהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושהם קיימת הסתמכות של בעל הרישיון על ההסכמה, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על הציפייה הלגיטימית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/576/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלחם (ראה: ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד ואח', פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח', פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ ואח', פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן ואח', פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו).

26. בשאלה מתי ניתן למנוע, מטעמי צדק, את ביטול הרישיון, גם אם הוא רישיון מכללא, נאמר כי "כללי הביטול של רישיון במקרקעין, מכל הסוגים, הוכפפו במהלך השנים לעקרונות של צדק, ובעיקרם שיקולי הסתמכות של בר-הרשות, והשבחת הנכס על ידו... ביצוע השבחות בנכס על-ידי המשתמש יוצר אצלו ציפיות להמשך השימוש. כאשר הבעלים היה ער לציפיות אלה ושתק, הוא עלול לאבד את זכותו לחזור בו מן ההרשאה, ויהיה עליו לכבד את ציפיות בר-הרשות להמשך השימוש בנכס. ההכרעה הסופית היא לעולם הכרעה נסיבתית" (מיגל דויטש קניין 415-414 (כרך שני, 1999)). גישה זו באה לידי ביטוי בפסיקה, כך למשל נפסק ברע"א 2701/95 כנעאן נ' גזאוי, פ"ד נג(3) 151, 170 (1999):

"כאשר מתעוררת בפני בית-המשפט טענה בדבר ביטול רישיון במקרקעין, ומתבקש סילוק ידו של בעל הרישיון מהמקרקעין עקב כך, על בית-המשפט לבחון, על-פי נסיבות המקרה, אם יהיה זה מן הצדק לאפשר לבעל המקרקעין לבטל את הרישיון ואם יש מקום להתנות את הביטול בתנאים. לעניין זה יתחשב בית-המשפט, בין היתר, בכוונת הצדדים לרישיון, בתנאי הרישיון, בציפייה שיצר בעל המקרקעין אצל בעל הרישיון, במידת הסתמכותו של זה האחרון על הרישיון שניתן ובנזק שנגרם לו עקב כך..."

27. ומן הכלל אל הפרט. במקרה הנדון יש לראות במעלית כמעלית מהווה חלק מהרכוש המשותף. כעולה מהרקע המשפטי לעיל, המעלית אינה מהווה דירה או חלק מהדירה, היא לא הוצמדה למי מדירות הנתבעים ואף לא לכל דירה אחרת. על כן, בשים לב להגדרה השיורית של המונח "רכוש משותף" בסעיף 52 לחוק, מדובר ברכוש משותף. אף אם ניתנה לנתבעים הזכות לעשות בה שימוש ייחודי במהלך השנים (והם אינם טוענים לכך אלא לזכות קניינית של ממש), הרי שמדובר לכל היותר ברשות במקרקעין אשר ניתן לחזור בה ממנה בכל עת. החריג הוא בעת קיומן של נסיבות מיוחדות כאשר קיימת הסתמכות, שינוי מצב לרעה ומתן תמורה - או אז תהיה זכות השימוש הייחודית בלתי הדירה, והכל בכפוף לעקרונות של צדק. הנתבעים לא טענו וממילא לא הוכיחו, כי הסתמכו על הרשות תוך שינוי מצב לרעה באופן המונע מבעלי הדירות לחזור בהם מהרשאתם. לא הוכח ולא נטען כי הנתבעים נתנו תמורה כלשהי לבעלי הדירות לשם קבלת זכות השימוש הייחודית. הנתבעים נשאו בעלויות הקמת המעלית וזו משמשת אותם מאז בנייתה ועד היום. התובעת אינה מבקשת להרוס את המעלית, למנוע מהנתבעים שימוש בה, או לסלק את ידם ממנה. אילו זה היה מבוקשה, לא מן הנמנע שניתן היה לומר כי נוכח ההסתמכות והנשיאה בעלויות השונות, שינוי הנתבעים מצבם לרעה באופן שלא מאפשר היום את הריסת המעלית וסילוק ידם משם (אלא בנסיבות מיוחדות וחריגות). כל מבוקשה הוא לאפשר לה להשתמש במעלית מבלי לפגוע בשימוש שעושים הנתבעים עצמם במעלית. היות שכך הדבר, אין היסוד הנדרש בדמות "הסתמכות ושינוי מצב לרעה" חל במקרה הנדון ולפיכך לא מדובר באותן נסיבות חריגות בהן זכות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/576/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

השימוש הייחודית היא בלתי הדירה. במקרה הנדון, לא מצאתי שיגרם נזק לנתבעים מביטול הרישיון למעט הנושא הכספי לו ניתן לתת מענה באמצעות החזר עלויות לנתבעים בהתאם לחלקה היחסי של התובעת בתשלום.

28. יש לדחות את טענת התובעים כי מדובר במעלית פרטית גם מן הטעם שלכאורה הסכימו כל בעלי הדירות על פסיעה במתווה של סעיף 59(ג)(1) לחוק, ולא לפי ברירת המחדל הקבועה בסעיפים 59(ב)(1) ו-59(ב)(3) לחוק. סעיף 59 (ג) (1) קובע כי **"בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם"**. במקרה הנדון לא טוענים הנתבעים להוראה בתקנון המוסכם, שאין חולק כי אינה קיימת ביחס למעלית, אלא להסכמה אחרת שאף לא הועלתה על כתב אלא בהתנהגות. משכך, וודאי שאין מדובר בהסכמה אליה כיוון המחוקק ועל כן אין כל רבותא בסעיף 59 (ג)(1) לעניינינו. מכל מקום, ברי כי נוכח השימוש הייחודי שהתאפשר לנתבעים במעלית אלו גם נשאו בכל הוצאות ההתקנה וההחזקה של המעלית לבדם. אין הדבר מלמד על הסכמה כלשהי הנוגעת להיקף התשלום שעל התובעת לשאת בו בעת הצטרפותה לשימוש במעלית. ממילא, לא הושג כל הסכם בין בעלי הדירות, לא בתקנון מוסכם ולא באופן אחר, הנוגע לגובה התשלום בו יישא בעל דירה המבקש להצטרף אל המעלית ולעשות בה שימוש.

29. אעיר כי בניגוד לטענת התובעת, הצמדה של מעלית דווקא עשויה להיות אפשרית מבחינת הדין. אמנם, סעיף 55 לחוק מורה כי לא כל חלקי הרכוש המשותף ניתנים להצמדה פיסית. כך, למשל, קובע הסעיף כי לא ניתן להצמיד **"חדרי מדרגות, מעלית, מקלטים ומתקנים שנועדו לשמש את כל בעלי הדירות"**. עם זאת, השאלה אם מתקן מסוים, כגון מעלית שנועדה לשמש רק חלק מבעלי הדירות ניתנת להצמדה נותרה בצריך עיון (ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נ' מרכוס, פ"ד מא (2) 561). בספרות המקצועית ובפסיקה הובעה דעה כי אין סיבה לשלול את האפשרות להצמדת הבעלות במעלית כזו רק לחלק מבעלי הדירות המשתמשים בה, ובלבד שניתנה לכך הסכמת כל יתר בעלי הדירות כנדרש בסיפא לסעיף 62 (א) לחוק קובע כי **"...אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"**. (ראה למשל דויטש, 683 י. וייסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף, חלק ב', בעמ' 399, ראה סקירת העמדות השונות ב- ת.א 125/94 מרז'ן נ' לוי, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 5.3.02) אציין כי גם מבחינה פרקטית, נרשמים בתים משותפים ביחס אליהם קובעות הוראות התקנון המוסכם הצמדה של מעלית לחלק מבעלי הדירות בלבד, כל עוד הן משמשות רק אותם. מכל מקום, במקרה דנן אין חולק כי המעלית לא הוצמדה לדירות הנתבעים ועל כן ממילא אין מדובר במעלית פרטית.

30. בנסיבות אלו, יש לדחות את טענת הנתבעים כי מדובר במעלית פרטית ובהתאם כי על התובעת לשאת במחצית ההוצאות. משמדובר במעלית המהווה חלק מהרכוש המשותף, יש לבחון את היקף השתתפותה של התובעת בעלויות הכרוכות במעלית בהתאם למסקנה זו.

31. בפסיקה ובספרות המקצועית חלוקות הדעות, אולם לאחרונה גוברת הנטייה לטובת העמדה כי זכות השימוש במעלית משותפת כפופה לתשלום עלות הקמתה לפי חלקם היחסי של בעלי הדירות המבקשים לעשות בה שימוש (ראה: ע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/576/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ת"א) 2704/75, מנטל נ' נציגות הבית המשותף [פורסם ב"נבו"], 21.6.06, , תיק (מפקח ת"א) 96/11, רוזין נ' נציגות הבית המשותף, [פורסם ב"נבו"] 14.4.11- להלן: "פרשת רוזין" א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק ג', 265). שותפה אני לעמדה זו, לפיה יש לחייב בעל דירה המבקש לעשות שימוש במעלית לאחר התקנתה, בחלקו היחסי. עמדתי היא כי יש לחייב את בעל הדירה בחלקו היחסי לפי שטח דירתו ביחס לשטחי יתר הדירות העושות שימוש במעלית ונשאו בהוצאות התקנתה. עמדה זו נגזרת מהאמור בסעיף 59 ו(ב) (1) לחוק, הקובע למעשה כי רק בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית יישאו בהוצאות ההתקנה, ולסעיף 59 ו(ב) (4) לחוק הקובע כי "התשלומים שבהם יישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות המבקש לעשות שימוש במעלית לאחר התקנתה, בחלקו היחסי, היינו לפי היחס בין שטח רצפת דירתו לבין יחס יתר שטחי "הדירות שבעליהן נושאים באותם תשלומים" (ראה בהקשר זה גם שנפסק בתיק 96/11 לעיל). לפיכך, יש לחייב בעל דירה המבקש לעשות שימוש במעלית לאחר התקנתה, בחלקו היחסי, היינו לפי היחס בין שטח רצפת דירתו לבין יחס יתר שטחי "הדירות שבעליהן נושאים באותם תשלומים", היינו הדירות שנשאו בעלות התקנת המעלית. במקרה דנן מדובר ביחס שבין שטח דירת התובעת לשטח דירתה ודירות הנתבעים יחד. לפיכך, יש לדחות את טענת התובעת כי יש לחייבה רק לפי חלקה היחסי אותו יש לקבוע בהתאם לשטח דירתה ביחס לכלל דירות הבית המשותף. היחס בין שטח דירת התובעת לשטחי דירתה ודירות הנתבעים יחד עומד על 33.4% (60.6/180.95).

32. עתה נותר לבחון מהן עלויות התקנת המעלית, כפי שהוכחו מהאסמכתאות שצירפו התובעים. העלויות לחברת המעליות אמיקופ בע"מ (להלן: "אמיקופ"), כפי שעולה מהאסמכתאות (נספח ד' לסיכומי הנתבעים) מגיע ל- 235,094.

33. התובעת טענה עוד כי יש להפחית עלות משוערת של עבודות שביצעו הנתבעים במעלית לאחר התקנתה (30,000 ₪ לפי אומדנה), משעה שמלכתחילה לא הותקנה כחוק. טענה זו הועלתה בשים לב לדברי הנתבע בדיון שהתקיים ביום 12.8.18, במהלכה אמר את הדברים הבאים: "שאנחנו בנינו את המעלית היא התנגדה בכל תוקף. היא הביאה מהנדס והמהנדס אמר חייב להיות 80 ס"מ ודאגנו לכך. פירקו בחזרה את הגבס והביאו למצב של 53 ס"מ" (עמ' 3 שורות 31-33). לטענתה מאחר שהסכם ההתקשרות עם אמיקופ לא צורף יש רק להניח כי נעשה ניסיון להסתיר את העלויות האמיתיות. הנתבעים טענו בהקשר זה כי העבירו את ההסכם עם אמיקופ לב"כ התובעת, וזאת כבר במסגרת הליכי הסעד הזמני (לתגובתם צירפו אסמכתא על משלוח פקס וכן אישור קבלה). כמו כן צירפו לתשובתם את ההסכם המלא עם חברת המעליות, בה מצוין כי סך העלות היא 53,000 \$. בנסיבות אלו, לא מצאתי כי נעשה כל ניסיון להסתיר את העלויות האמיתיות. בשים לב להסכם ומלוא הקבלות שצורפו לא מצאתי בסיס לדרישת התובעת לבצע הפחתה כמבוקש.

34. לגבי נספח ד'2- התובעת לא התנגדה לחישוב עלויות נוספות שצורפו לאסמכתאות הנתבעים (בקשה לחיבור מים/ תוספת בנייה- 248 ₪, תשלום לעיריית גבעתיים 1,429 ₪, היטל אגרה 1,181 ₪, תשלומים לחברת החשמל 3,867.54 ₪, תשלום נוסף לחברת חשמל- 389.97 ₪. בסך הכל- 7,115.5 ₪. יוצא, כי סך כל עלויות התקנת המעלית, כולל תשלום לאמיקופ הן 242,209 ₪ סכום קרן .



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/576/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. יש לדחות את טענת הנתבעים כי יש לחייב את התובעת בהוצאות אחזקה ותחזוקה בתקופה בה לא הייתה לה זכות שימוש במעלית. כפי שצוין לעיל, שעה שמדובר במעלית שניתנה בה לנתבעים זכות שימוש ייחודית, ממילא הייתה כפופה זכות זו לנשיאה בכל העלויות הכרוכות בכך לבדם. הדבר היה מקובל גם על הנתבעים שכן אלו לא הלינו במהלך השנים על כך שהם נושאים לבדם בכל הוצאות האחזקה וההפעלה של המעלית ונראה כי כך התקבע הנוהג בבית המשותף. יתרה מכך, בחיובה של הנתבעת בהוצאות תחזוקה והפעלה של המעלית מאז התקנתה מבלי שהייתה לה בה כל זכות שימוש, יש משום עשיית עושר ולא במשפט, זאת ממש כשם שיש עשיית עושר ולא במשפט כאשר בעל דירה מבקש לעשות שימוש במעלית מבלי לשאת בהוצאות התקנתה. יתרה מכך, לו אכן סבורים הנתבעים כי יש לחייב את בעלי הדירות בחלקם בהוצאות האחזקה וההפעלה של המעלית בשים לב להוראת סעיף 159, תמוה כי הם מבקשים לעשות כן רק ביחס לתובעת ולא ביחס לבעלי דירות אחרים. הדבר עצמו מלמד כי אלו בנו את המעלית תוך הבנה עם יתר בעלי הדירות כי הם היחידים שיישאו בהוצאות תחזוקה והפעלה. עם זאת מובן, כי מעת שניתנה לתובעת זכות השימוש במעלית עליה לשאת בחלקה היחסי בעלויות התקנת והחזקת המעלית ממועד זה ואילך, ולכך אף הגיעו הצדדים לכדי הסכמה במסגרת הדיון בסעד הזמני.

36. גם את טענת הנתבעים כי יש לחייב את התובעת בנזקיהם הנתענים יש לדחות. טענה זו מבוססת על השקפת הנתבעים לפיה בשל התנגדות התובעת לבניית המעלית, נאלצו לשאת בהוצאות שכירת דירה והובלה אליה. הנתבעים לא הוכיחו כלל כי מדובר בנזקים שנגרמו להם כטענתם, בשל התנהלות התובעת וזו הכחישה את הנטען מכל וכל. לא הוכח עיכוב בהתקנת המעלית וממילא היקפו, לא הוכח שככל שהיה עיכוב הוא נגרם אך בשל התנהלות התובעת, לא הוכח כי עיכוב זה היה כרוך בהכרח בצורך בשכירת דירה חלופית במשך שנה וכיוצא. בנסיבות אלו לא מצאתי כל בסיס להשית על התובעת את נזקי הנתבעים כנטען.

37. בהקשר זה יש להעיר כי על אף שמובנת לי תחושת אי הנחת של הנתבעים מכך שהתובעת, שהתנגדה באופן פעיל לבניית המעלית, מבקשת כעת לעשות בה שימוש, אין בכך כדי להצדיק להטיל עליה נטל כבד יותר של תשלום ביחס לכל בעל דירה אחר שהיה מבקש לעשות שימוש במעלית, במיוחד שעה שטענת הנזק כלל לא הוכחה.

38. אין בידי לקבל את טענת התובעת כי מסכום החיוב יש לקזז סכום של 1,000 ₪ עבור התאמות שבוצעו במעלית. הצדדים הסכימו מפורשות, כפי שפורט לעיל, כי בעלויות התאמת המעלית לצרכי התובעת תישא לבדה כל עוד לא יעלו על 3,000 ₪- "המבקשת תישא עצמה בכל עלויות התאמת המעלית לעצירה בקומה הראשונה בה ממוקמת דירתה כל עוד הסכום לא יעלה על 3,000 ₪. ככל שהעלות תהיה מעבר ל-3,000 ₪ יקבע בסיום ההליך מי צריך לשאת בעלות שמעבר לסכום זה".

39. באשר למחלוקת בין הצדדים בנוגע להפרשי ריבית הצמדה, עמדתי היא כי יש לחייב את הנתבעת בהפרשי הצמדה ללא הפרשי ריבית. ביחס להפרשי הצמדה נפסק כי "החיוב בהפרשי הצמדה אין בו לא הטלת עונש או קנס על החייב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/576/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ולא מתן פרס לנושה. מטרתו להשיב לנושה את כספו לפי ערכו הריאלי. רק במקרים יוצאים מן הכלל יימנע בית המשפט מלעשות שימוש מלא בסמכותו לצוות על הפרשי הצמדה" (ע"א 160/84 יהלומי פלנת בע"מ נ' דוד פינסקי פ"ד מ (4) 372- להלן: "פרשת יהלומי"). לעומת זאת, בנושא הריבית נאמר בפרשת יהלומי כי "חיוב ריבית מטרתו לפצות על השימוש בכספו של הנושה". במקרה הנדון הייתה זכאית התובעת שלא להשתתף בעלות ההתקנה וכפועל יוצא לא לעשות במעלית כל שימוש. רק בעת האחרונה, בשים לב לגילה ומצבה הרפואי, מבקשת התובעת לעשות שימוש במעלית. אי לכך, אין מדובר בהתגבשות חוב ביחס לתובעת שנוצר בעת התקנת המעלית ומצדיק לחיבה בריבית. ברי, כי חובת הנתבעת להשתתף בעלויות ההתקנה נוצרה רק מעת שהחלה לעשות בה שימוש בפועל (ראה בהקשר זה גם שנפסק בפרשת רוזין, בתיק (מפקח י-ם) 92/11, גיניאה נ' קורפו [פורסם ב"נבו"], ניתן ביום 16.8.12), ובפסק דיני בפרשת כהן).

40. יש לדחות את טענת הנתבעת כי יש לחייב בהפרשי הצמדה רק עד ליום 1.3.18, או אז פנתה אל התובעים בבקשה לעשות שימוש במעלית, שכן זכאותם של הנתבעים לקבל את ערך הכסף במלואו מבלי שיוותר כל חיסרון כיס. בשים לה להסכמות שהושגו במהלך הדיון בצו המניעה הזמני ביום 12.8.18 ולתשלום של 75,000 ₪ ששילמה הנתבעת בסמוך, מצאתי לנכון לחשב את פסיקת ההצמדה מיום התשלום ועד ליום 1.8.18.

41. סיכומי של דבר הוא כי הסכום הכולל עבור התקנת המעלית, בתוספת הפרשי הצמדה, עומד על 299,807 ₪ (ראה נספח 7 לסיכומי התובעת). חלקה של התובעת בתשלום הוא 33.4%, היינו בסך הכל 100,135 ₪. מתוך סכום זה שילמה זה מכבר התובעת סך של 75,000 ₪ ועל כן נותר לה לשלם סך של 25,135 ₪.

ד. סוף דבר

42. התובעת תשלם לנתבעים סך נוסף של 25,135 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מהיום ולאחר מכן יישא בהפרשי ריבית והצמדה כדין. הנתבעים יאפשרו לתובעת להמשיך ולעשות שימוש במעלית.

43. בהתאם להסכמת הצדדים, תישא התובעת בשליש מהוצאות אחזקתה ותחזוקתה השוטפות של המעלית החל מיום 15.8.18.

44. בשים לב לתוצאות ההליך, יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ט, 30 ינואר 2019, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין